Poder Judiciário
Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul
2ª Vara Cível da Comarca de Taquara

Rua Ernesto Alves, 1750 - Bairro: Recreio - CEP: 95600354 - Fone: (51) 3542-1933 - Email: frtaquara2vciv@tjrs.jus.br

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL Nº 5002228-50.2021.8.21.0070/RS

AUTOR: PAULO RICARDO GALLAS
RÉU: ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

SENTENÇA

Vistos, etc.

PAULO RICARDO GALLAS ajuizou ação em desfavor do **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL,** objetivando o fornecimento de medicamento.

A parte autora, em síntese, referiu que foi diagnosticado com Neoplastia Maligna da Pele – estágio III C – T4N1b (CID10 C44.9), a fazer uso do medicamento PEMBROLIZUMAB 100 mg/4 ml (200 mg a cada 21 dias). Afirmou não possuir condições financeiras de custear o tratamento, tendo em vista que o valor unitário da medicação perfaz o montante de R$ 18.298,70. Pugnou pela concessão do benefício da gratuidade da justiça. Requereu, em sede de liminar, o fornecimento do fármaco ora pleiteado. Postulou a procedência da demanda. Juntou documentos (evento 1).

Intimou-se a parte autora para demonstrar a existência de registro na Anvisa do fármaco objeto da lide (evento 3, DESPADEC1), o que foi atendido (evento 5, OUT2).

Concedeu-se o benefício da gratuidade da justiça ao requerente e deferiu-se o pleito liminar (evento 7, DESPADEC1).

Houve bloqueio de valores (evento 17, DESPADEC1 e evento 75, DESPADEC1), tendo a parte autora prestado contas (evento 25 e evento 86), as quais foram homologadas diante da concordância do réu (evento 32, PET1 e evento 90, PET1).

Citado (evento 18), o demandado apresentou contestação (evento 23, CONT1). Alegou, preliminarmente, a de intimação da parte autora para emendar a inicial, incluindo a União no polo passivo, com a consequente remessa dos autos à Justiça Federal. No mérito, discorreu acerca da política nacional de prevenção e controle do câncer. Aduziu que, uma vez confirmado o diagnóstico do câncer no âmbito da rede pública, o paciente deve ser encaminhado para o centro de referência para tratamento oncológico (CACON ou UNACON), os quais são responsáveis pela confirmação diagnóstica dos pacientes, estadia, assistência ambulatorial e hospitalar, atendimento das emergências oncológicas e cuidados paliativos. Ressaltou que não compete ao gestor estadual o financiamento ou a definição dos medicamentos que serão ou não utilizados no tratamento da doença, de modo que, pela legislação vigente, as atribuições do Estado do Rio Grande do Sul na política oncológica são reduzidas. Teceu considerações acerca das custas processuais e da verba honorária. Postulou a improcedência da demanda. Subsidiariamente, em caso de procedência do feito, requereu seja determinado o fornecimento do medicamento pela Denominação Comum Brasileira, conforme determina o artigo 3º da Lei nº 9.787/99 (Lei do Medicamento Genérico), bem como seja condicionando o fornecimento do fármaco à apresentação semestral pela parte autora de receituário médico atualizado. Juntou documento.

Sobreveio réplica (evento 30, PET1), ocasião em que a parte autora rebateu os argumentos expendidos pelo demandado.

Instadas as partes acerca do interesse na dilação probatória (evento 36, DESPADEC1), o autor anexou laudo médico (evento 42, LAUDO2), enquanto que o réu afirmou não ter outras provas a produzir (evento 19), enquanto que o Estado reiterou o item "c" da contestação (evento 45, PET1).

Intimada a parte autora para informar se buscou atendimento junto a um CACON/UNACON (evento 47, DESPADEC1), esta acostou comprovante de marcação de consultas no Instituto de Oncologia Kaplan – unidade Oncoprev, o qual é possui classificação como UNACON anexa ao Hospital Bom Jesus de Taquara/RS (evento 49, COMP2).

Intimado acerca do documento anexado pelo requerente (evento 51, DESPADEC1 e evento 52), o réu manifestou ciência (evento 55, PET1).

Intimada a parte autora para informar se ainda faz uso da medicação objeto da lide (evento 113, DESPADEC1), esta referiu que foi realizado o 14º ciclo, sendo que o tratamento anual demanda 18 ciclos e com intervalo de 21 dias. Ainda, mencionou que, após a décima oitava aplicação, passará por nova avaliação médica para análise de eventual continuidade de tratamento (evento 117, PET1).

O Ministério Público declinou de intervir no feito (evento 128, PROMOÇÃO1).

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decide-se.

1. Da preliminar de intimação da parte autora para emendar a inicial, incluindo a União no polo passivo.

A preliminar em tela confunde-se com o mérito e, por isso, será com ele analisada.

Sem mais preliminares aventadas, nem nulidades a serem sanadas, enfrenta-se o mérito.

2. Do mérito.

Cuida a espécie de ação que busca a preservação do direito à saúde em que se postula o fornecimento de medicamento.

Ora, a Constituição da República Federativa do Brasil elenca, dentre os direitos fundamentais, com aplicação imediata (art. 5º, § 1º, da Lei Maior), o direito à vida (art. 5º, *caput*) e à saúde (art. 6º). Tais direitos dão corpo ao Princípio Fundamento da Dignidade da Pessoa Humana (art. 1º, 'III', CRFB). Aqui no Rio Grande do Sul, o art. 241 da Constituição Estadual segue a mesma linha, restando certo, portanto, o dever estatal de garantir uma política pública efetiva para esta área social tão sensível.

Com efeito, a Lei Maior estabelece, outrossim, o cuidado com a saúde como competência comum da União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, 'II'); declarando também que "*a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação*" (art. 196).

Ainda, a Lei nº 8.080/90, que regulamenta o Sistema Único de Saúde - SUS, dispondo sobre as condições para a promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos serviços correspondentes, reza, em sua Disposições Gerais:

> *"Art. 2º - **A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício.***
>
> *§ 1º O dever do Estado de garantir a saúde consiste na formulação e execução de políticas econômicas e sociais que visem à redução de riscos de doenças e de outros agravos e no estabelecimento de condições que assegurem acesso universal e igualitário às ações e aos serviços para a sua promoção, proteção e recuperação. (...)". - Grifou-se.*

Assim, deve ser garantido a todos indistintamente o direito ao bem estar físico e mental, no que os entes federados prestá-lo-ão de forma solidária, a quem necessitar. Nesse sentido, a orientação pacificada na Suprema Corte:

> *"AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. **DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO PELO PODER PÚBLICO DO TRATAMENTO ADEQUADO. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. NÃO OCORRÊNCIA. COLISÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS. PREVALÊNCIA DO DIREITO À VIDA.** PRECEDENTES.*
>
> *A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que, apesar do caráter meramente programático atribuído ao art. 196 da Constituição Federal, **o Estado não pode se eximir do dever de propiciar os meios necessários ao gozo do direito à saúde dos cidadãos. O Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas nas questões relativas ao direito constitucional à saúde. O Supremo Tribunal Federal entende que, na colisão entre o direito à vida e à saúde e interesses secundários do Estado, o juízo de ponderação impõe que a solução do conflito seja no sentido da preservação do direito à vida.** Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada.*
>
> *Agravo regimental a que se nega provimento."*
>
> *(ARE Nº 801676 AGR/PE, REL. MIN. ROBERTO BARROSO, PRIMEIRA TURMA) - Grifou-se.*
>
> *"CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. **DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. PRECEDENTES.** 1. **A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.** 2. Ressalva da posição pessoal em sentido contrário, manifestada em voto proferido na 1ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp 888975/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/ Acórdão Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, DJ 22/10/2007). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.(ARE 803274 AgR, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13/05/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-101 DIVULG 27-05-2014 PUBLIC 28-05-2014)" - Grifou-se.*

No mesmo sentido, cita-se decisão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

> *"AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. **LEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERATIVOS. A Constituição Federal estabeleceu a responsabilidade solidária dos entes federativos pela prestação dos serviços de saúde, de modo que todos os entes públicos têm legitimidade para responder às demandas que visam ao fornecimento gratuito de medicamentos. Divisão de competência no âmbito da gestão interna do Sistema Único de Saúde que não deve ser oponível contra o particular.** Não-configuração de ilegitimidade passiva do Município. ACESSO À SAÚDE. PROTEÇÃO SUFICIENTE. O acesso à saúde é direito fundamental e as políticas públicas que o concretizam devem gerar proteção suficiente ao direito garantido, sendo passíveis de revisão judicial, sem que isso implique ofensa aos princípios da divisão de poderes, da reserva do possível ou da isonomia e impessoalidade. LEI 8.080/90. ALTERAÇÕES. LEI 12.401/11 E DECRETO 7508/11. O reconhecimento da insuficiência das listas oficiais, na situação concreta, não implica negativa de vigência às normas que regulam o direito à saúde. Trata-se de controle judicial dos atos normativos dos órgãos do SUS à luz das diretrizes legais (eficácia, segurança, efetividade e custo-efetividade). AGRAVO DE INSTRUMENTO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de Instrumento Nº 70061903019, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 02/10/2014)" - Grifou-se.*

Assim, compete aos entes federados, solidariamente, a responsabilidade pelo fornecimento de medicamentos e de tratamento médico a quem necessitar e não possuir condições de custeá-lo. Com isso, **REJEITA-SE** a prefacial de inclusão da união no polo passivo da demanda.

Afora isso, quanto ao tema da Saúde, a Doutrina tem se manifestado[1]:

> *"(...) **Verifica-se uma forte tendência jurisprudencial e doutrinária no sentido do reconhecimento de posições subjetivas, inclusive originárias, decorrentes do direito à Saúde na condição de direito a prestações, seja nas hipóteses de iminente risco para a vida humana - como aliás, amplamente reconhecido no direito estrangeiro -, seja naquelas em que a prestação possa ser reconduzida à noção de mínimo existencial, ou seja, à garantia de condições mínimas à vida com dignidade e certa qualidade.** Nesse sentido, cabe referência ao precedente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE-AgR n.271.286/RS (DJ de 24.11.2000), a partir do qual a jurisprudência não apenas dos Tribunais Superiores, mas também nas instâncias ordinárias, vem reiterando a possibilidade de reconhecimento de posições subjetivas originárias às mais diversas prestações materiais, **com vistas à efetivação do direito à saúde (fornecimento de medicamentos, reserva de leitos hospitalares, ordem de realização de exames e procedimentos, etc). Quanto à garantia do mínimo existencial,** não se pode deixar de salientar o precedente estabelecido no julgamento da ADPF-MC n. 45 (DJ 04-05-2004), que apesar da extinção da ação por superveniente perda de objeto, **asseverou que a efetivação do direito à saúde liga-se à garantia de proteção ao mínimo existencial, devendo-se interpretar "com reservas" a alegação, por parte do Estado, de violação à reserva do possível** (...)" - Grifou-se.*

No mais, ainda que o tratamento de neoplasia maligna seja realizado através de órgãos específicos (CACONs ou UNACONs), conforme previsto nas Portarias nº 741/2005 e nº 3.535/98 do Ministério da Saúde, tal fato **não** afasta a responsabilidade do demandado, já que o direito à saúde é dever do Estado, garantido por todos os entes da federação de modo indistinto. Aliás, assim se posiciona a Jurisprudência do E. Tribunal de Justiça em casos análogos:

> *"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. BORTEZOMIBE. SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS. INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. DESNECESSIDADE. CACON. LISTAS DO SUS. TEMA 106 DO STJ. 1. Com base nos artigos 6º e 196 da Constituição Federal, é crível admitir que é dever do Estado (lato sensu) prestar atendimento de saúde, quando configurados os vetores da adequação do medicamento, tratamento ou cirurgia e da carência de recursos financeiros de quem postula. 2. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Recurso Extraordinário nº 855178/RG, com repercussão geral, reafirmou sua jurisprudência quanto à responsabilidade solidária dos entes federados nas questões relativas ao direito à saúde. 3. **Para os pacientes portadores de neoplasias malignas todo o tratamento é realizado através de órgãos específicos, os Centros de Alta Complexidade em Oncologia – CACONs, vinculados à União. Tal fato, todavia, não retira o dever dos entes públicos de atendimento à saúde.** 4. A parte demandante, por meio de atestado médico, comprovou a necessidade da utilização do medicamento para o tratamento de sua saúde. Igualmente ficou demonstrado que a parte autora enquadra-se na condição de necessitada, não possuindo condições financeiras de arcar com os gastos necessários ao tratamento. 5. O TEMA 793 do STF reafirmou a responsabilidade solidária dos entes públicos, tendo esta Corte já decidido que "eventual ressarcimento entre os obrigados poderá ser realizado na esfera administrativa, ou por meio de ação própria, mesmo que a presente demanda tenha sido ajuizada contra Estado e Município, não havendo que se falar em prejuízo maior a qualquer um deles". 6. Preenchimento dos requisitos estipulados pelo STJ no julgamento do REsp 1657156/RJ (Tema 106), onde admitida a possibilidade do fornecimento de medicamentos não constantes dos atos normativos do SUS, em caráter excepcional. 7. Nas hipóteses de sentença condenatória ilíquida proferida contra a União, o Estado, o Distrito Federal, o Município e as respectivas autarquias e fundações de direito público interno, é obrigatória a remessa necessária contemplada pelo artigo 496 do Código de Processo Civil. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.(Apelação Cível, Nº 70084934785, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Leonel Pires Ohlweiler, Julgado em: 08-05-2021)" - Grifou-se.*

> *"APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. SÁUDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - VOTRIENT 400MG (CLORIDRATO DE PAZOPANIBE). DEMANDANTE PORTADOR DA PATOLOGIA ESPECIFICADA PELO CID10 C64 (CARCINOMA RENAL DE CÉLULAS CLARAS). RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL DO RE Nº 566.471/RN (TEMA 6/STF). CACON E UNACON. MEDICAMENTO FORA DAS LISTAS DO SUS. ALTO CUSTO DO FÁRMACO. ALEGAÇÕES DE NATUREZA ORÇAMENTÁRIA. DESPROVIMENTO. 1. O reconhecimento da repercussão geral no RE nº 566.471/RN, pelo STF, não impede o julgamento da apelação, eis que ainda não julgado o recurso em definitivo, o qual aguarda tese a ser fixada. 2. Ainda que o tratamento de neoplasias (câncer) deva ser fornecido pela União, através de um dos Centros ou Unidades de Alta Complexidade em Oncologia (CACON ou UNACON), é dever dos demais entes federados realizar o encaminhamento do paciente ao respectivo centro, assim como providenciar o fornecimento dos medicamentos solicitados, notadamente quando os referidos centros não disponibilizam a medicação necessária. 3. A falta de inclusão do medicamento pleiteado nas políticas públicas existentes no âmbito da saúde e/ou nas listas administrativas daqueles fornecidos pelo SUS não exime os entes federados do custeio dos tratamentos médicos pleiteados pelos cidadãos, porquanto questões administrativas não podem se sobrepor ao direito assegurado pela Constituição Federal. 4. Permanece inarredável a responsabilidade do ente estadual pelo fornecimento do serviço de saúde postulado mesmo frente às alegações quanto ao alto custo do fármaco. Isso porque questões de ordem orçamentária, notadamente quando invocadas de forma abstrata, não podem se sobrepor às disposições constitucionais que tutelam o direito à saúde, à dignidade humana e à vida. APELAÇÃO DO ESTADO DESPROVIDA. UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 50039494320198210026, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em: 05-05-2021)" - Grifou-se.*

Ora, **no caso dos autos**, está comprovada a necessidade e urgência de utilização do medicamento PEMBROLIZUMAB 100 mg/4 ml - 200 mg a cada 21 dias e a impossibilidade de substituição pelas alternativas disponíveis no SUS (evento 1, LAUDO8); a negativa do fornecimento pelo poder público (evento 1, CERTNEG11) e a existência de registro na Anvisa (evento 5, OUT2).

Ademais, o requerente e seus familiares não possuem recursos financeiros para custear o tratamento, notadamente em razão de seu elevado custo (conforme orçamentos juntados no evento 1, OUT12), ficando comprovados os pressupostos implementados pelo julgamento do Recurso Especial nº 1.657.156/RJ, concernentes ao tema 106 do STJ.

Salienta-se ainda que a ausência do fármaco nas listas públicas de remédios disponibilizados pelo SUS não pode vir em prejuízo ao cidadão que se encontra doente, devendo os entes públicos realizarem, entre si, o devido acerto administrativo, com observância à responsabilidade solidária imposta à federação. Nessa linha, a jurisprudência:

> *"(...) FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. (...) LEGITIMIDADE PASSIVA. ENTES FEDERADOS. COMPETÊNCIA COMUM. SOLIDARIEDADE. (...). LISTAS DE MEDICAMENTOS DO SUS.*
>
> ***A ausência do fármaco nas listas do SUS não afasta a responsabilidade, prevista constitucionalmente, do Poder Público pelo fornecimento de medicamentos aos necessitados, garantindo assim o mínimo existencial.** (...)*
>
> *NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO."*

(AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 70047564893, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: JORGE MARASCHIN DOS SANTOS, JULGADO EM 23/02/2012) – Grifou-se.

Outrossim, a parte autora, em contrapartida, deverá comprovar ao réu, periodicamente, a necessidade de continuidade do tratamento. Neste caso, semestralmente, por intermédio de atestado médico.

Da Denominação Comum Brasileira (DCB) e do medicamento genérico.

Por derradeiro, consigna-se que, consoante previsto no art. 3º da Lei nº 9.787/99, seja observado, se possível, na aquisição dos fármacos, a Denominação Comum Brasileira (DCB), assim como seja dada preferência, quando houver, à compra de medicamento genérico, em igualdade de preço.

Logo, a procedência da demanda é a medida que se impõe.

Do dispositivo.

Ante o exposto, rejeita-se a prefacial e, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, **JULGA-SE PROCEDENTE** o pedido formulado na presente demanda, razão pela qual **CONDENA-SE** o **ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL** ao fornecimento ao autor dos medicamentos **PEMBROLIZUMAB 100 mg/4 ml**, enquanto perdurar a necessidade. Por consequência, confirma-se a liminar deferida no evento 7, DESPADEC1. Consigna-se que o demandante deverá entregar ao requerido atestado médico semestral que comprove que a necessidade dos fármacos persiste, bem como observar, se possível, na aquisição dos fármacos, a Denominação Comum Brasileira (DCB), assim como seja dada preferência, quando houver, à compra de medicamento genérico, em igualdade de preço.

O Estado do Rio Grande do Sul é isento da Taxa Única Judiciária, nos termos do art. 5º, inciso I, da Lei Estadual nº 14.634/14. Condeno-o, no entanto, ao pagamento de eventuais despesas processuais, exceto as de condução. Sem condenação em honorários, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos da súmula 421 do STJ[2].

A sentença está sujeita ao reexame necessário, consoante entendimento da Súmula nº 490 do STJ[3].

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Com o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com baixa.

Diligências legais.

Documento assinado eletronicamente por **FABIO BASALDUA MACHADO, Juiz de Direito**, em 29/3/2023, às 18:9:9, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://eproc1g.tjrs.jus.br/eproc/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, informando o código verificador **10032028319v13** e o código CRC **dc2e468b**.

---

1. "(Sarlet, Ingo Wolfgang. In Comentários à Constituição do Brasil/J.J. Gomes Canotilho... et al.] São Paulo: Saraiva/Almedina, 2013)" ↩
2. "Os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença". ↩
3. "Súmula 490 - A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas". ↩